

1500327-89.2020.8.26.0511

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... senão veja-se: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO, DE OFÍCIO. 3. A majoração da pena-base quanto ao delito de tráfico de drogas não se sustenta, tendo em vista que a quantidade de drogas encontradas em poder do paciente não é expressiva. Narra a exordial acusatória que foram apreendidos 17,6 g de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro - CEP 13390-000, Fone: (19) 3493-1125, Rio Das Pedras-SP - E-mail: riодaspedras@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ASSENTADA

Processo Digital nº:

1500327-89.2020.8.26.0511 - Ordem nº 2021/000181

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado -

3078928/2020 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 13824302 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 57/2020 -

Delegacia de Polícia de Rio das Pedras

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MAYCON WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Data da audiência

28/03/2022 às 15:00h

Em 28 de março de 2022, às 15 horas, nesta cidade de Rio das Pedras, Comarca de Rio das Pedras, no Foro de Rio das Pedras, na sala de audiências da Vara Única, presente o Excelentíssimo Sr. Dr. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO, MM Juiz de Direito, comigo escrevente. Também COMPARECERAM: O representante do Ministério Público, Dr. Eduardo Henrique Balbino Pasqua; o Réu: MAYCON WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS; o Defensor Dr., Estevan Tozin; e as testemunhas: Richard Cesarino. Em seguida, com as formalidades legais, o MM Juiz de Direito passou a ouvir, a testemunha e interrogar o réu, tudo gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídias anexadas aos autos. Após, pelas partes foi dito que não tinham mais provas a produzir. Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça para alegações finais orais, o que foi gravado por meio de sistema audiovisual, conforme vídeo anexado aos autos. Dada a palavra ao Dr. Defensor para alegações finais orais, assim se manifestou: "MAYCON WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos do processo supra indicado, por seu advogado dativo nomeada, vem a presença de Vossa Excelência, apresentar seus MEMORIAIS com fulcro no art. 403, parágrafo 3,

do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. I – Dos Fatos. Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 18h10, na Avenida Rosina Figureli Coury, 1800, Núcleo Habitacional Lucia Taranto Marrano, neste município e comarca de Rio das Pedras, MAYCON WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 89, fotografia a fls. 90, trazia consigo e guardava 23 porções de maconha (massa líquida: 39,2 + 3,2 gramas) e 2 porções de crack (massa líquida: 0,3 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para distribuição, comercialização e entrega. O laudo pericial foi juntado a fls. 18-26. Interrogado pela Autoridade Policial, o acusado em fls. 89, afirmou que se encontrava no local dos fatos na companhia do colega RONILSON DA CRUZ NUNES DOS SANTOS, de 18 anos de idade para adquirir drogas para seu consumo já que é dependente químico da droga conhecida popularmente como crack, quando foram abordados por policiais militares, no entanto assevera o declarante que ainda não havia adquirido o entorpecente e após revista pessoal foi liberado juntamente com RONILSON. Frisa que logo em seguida retornou ao local naquela ocasião adquiriu a pedra de Crack no valor de R\$ 5,00 (cinco reais) de um rapaz que não recorda o nome. Diz que após fazer uso da droga que acabara de adquirir foi novamente abordado e revistado pelo policial militar, no entanto nada localizaram. Afirma que os policiais fizeram buscas pelas imediações e localizaram certa quantidade de drogas e logo após foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência. O declarante afirma que é usuário de Crack, e naquela ocasião não portava nenhum tipo de entorpecente. A droga localizada pelos policiais militares não é de sua propriedade e desconhece a quem pertença Em fls. 79 o Delegado de Polícia responsável pelo caso após averiguar todas as os fatos e provas na conclusão da investigação afirma que não foi possível apontar o acusado como responsável pelo entorpecente encontrado a certa distância. Em fls. 80 o Investigador de Polícia afirma que após verificar o disque denúncias não logrou êxito em encontrar denúncias sobre o local da ocorrência, pessoas com as características, prenome ou apelido da dupla investigada. Não sendo possível estabelecer a origem e propriedade do entorpecente. II – Do Direito. Durante a instrução de todo o processo, evidencia-se que não foram apresentadas provas inequívocas que comprovem o envolvimento do acusado com os objetos encontrados. Ressalte-se que a autoridade policial em sua conclusão de folhas 79/81 afirma que não é possível apontar o acusado como responsável pelo entorpecente encontrado a certa distância, não sendo possível estabelecer a origem e propriedade do entorpecente. Ressalte-se que o acusado é usuário de drogas e atualmente está internado em tratamento, e na data dos fatos estava passando pelo local, pois foi adquirir o entorpecente do qual é dependente, porém nada foi encontrado com ele. Não se pode perder de vista que o único objeto encontrado com o acusado foi o dinheiro R\$ 33,00 (trinta e três reais), em diversas notas e não em “trocado”, que pudesse caracterizar que seria utilizado como “troco” para comercialização, frise-se ainda que tal valor não poderia ser utilizado como “troco” para a quantidade de droga encontrada. De todo o exposto, fica patente que não há provas suficientes para incriminar o acusado, neste sentido é o entendimento da Jurisprudência: “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO - Recurso provado havendo o conjunto probatório resultado precário para demonstrar que o apelante trazia consigo, certa quantidade de substância entorpecente, sem autorização legal, importa prover-se o recurso para absolvê-lo da imputação que lhe pesa, com a conseqüente expedição do alvará de soltura.” (Apelação Criminal – 6ª Câmara Criminal, Proc. nº 2002.050.01891, Dês. Maurício da Silva Lintz) (grifo nosso) Ponto importante a ser ressaltado é que a própria autoridade policial em sua conclusão do referido caso confirma a versão apresentada pelo acusado, certo que o acusado não portava consigo qualquer objeto ilícito. Destaca-se que para a condenação de alguém por qualquer delito, é necessária prova certa da autoria. Diante da incerteza e falta de robustez na prova produzida, há que absolver o réu, trata-se de imposição legal, e no caso dos autos, não há provas reais e concretas de que o acusado realmente tivesse envolvimento com a droga encontrada no local, como já exaustivamente comprovado, assim, a jurisprudência dos Tribunais entendem que o réu deve ser absolvido. Vejamos assim uma jurisprudência que se aplica ao

caso em discussão. "TJRS - Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'" (RJTJRS 177/136). No caso em concreto, não existem provas suficientes para que possam imputar o Acusado como traficante, pois a própria narrativa dos policiais sobre os fatos ocorridos não comprovam que a droga encontrada era do Acusado, bem como o Investigador de Polícia afirma que após verificar o disque denúncias não logrou êxito em encontrar denúncias sobre o local da ocorrência, pessoas com as características, prenome ou apelido da dupla investigada, não sendo possível estabelecer a origem e propriedade do entorpecente. O Direito Penal não admite meras presunções para a condenação de uma pessoa, sendo assim, de acordo com o exposto, requer a absolvição do Acusado, nos moldes do artigo 386, V, VI, VII, do Código de Processo Penal. Neste sentido dispõe Damásio de Jesus: Cremos que o art. 5º, LVII, da CF, que instituiu o princípio segundo qual o réu, enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória, deve ser considerado inocente, revogou o inc. VI do art. 386 do CPP. Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, paira "dúvida razoável" sobre a sua existência, "não pode ser tido como provado", i.e., deve ser considerado inexistente, não provado (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no processo penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45, n. 1). Da forma como consta do inciso, porém, dá o texto a entender que há prova no sentido da ocorrência do fato, só que insuficiente para a condenação. Contra: TACrimSP, ACrim 653.683, 9ª Câmara, RT 677/371; TJSP, RT 788/589. Em caso completamente análogo, dispõe a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO - LESÕES CORPORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - ABSOLVIÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Havendo dúvidas nos autos e contradições, a absolvição é medida que se impõe. (...) As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado às partes, não podendo a versão de uma ter um peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0329.07.001090-8/001 - COMARCA DE ITAMOJI - APELANTE(S): TIAGO DE CARVALHO CARDEAL - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, deverá ser aplicado a pena para o mínimo legal, isto porque "supostamente" fora apreendida uma pequena quantidade de entorpecente, não podendo ser considerada essa quantidade tão significativa, dessa forma, deve-se afastar essa valoração negativa ao presente caso, respeitando-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO, DE OFÍCIO. 3. A majoração da pena-base quanto ao delito de tráfico de drogas não se sustenta, tendo em vista que a quantidade de drogas encontradas em poder do paciente não é expressiva. Narra a exordial acusatória que foram apreendidos 17,6 g de maconha, acondicionados em 2 porções, quantidade esta que não pode ser considerada elevada a ponto de ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legalmente permitido. (STJ - HC: 311896 DF 2014/0332381-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/05/0005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015) (grifo nosso) "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INOCORRÊNCIA. O Superior Tribunal de Justiça entende como motivação inidônea a exasperação da pena-base pelas natureza e quantidade de droga, quando a substância entorpecente apreendida não é significativa. (STJ - HC 155018 SP 2009/0232424-1, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Julgamento: 06/12/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2012) (grifo nosso) Todavia, o fato de ser hediondo por equiparação não poderá implicar na fixação automática do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, isso porque o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na

data de 27 de junho 2012 (Habeas Corpus n.º 111.840), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º 11.464/07, o qual prevê que a pena dos crimes hediondos e equiparados será cumprida, inicialmente, em regime fechado. Na ocasião, estabeleceu a Suprema Corte que o § 1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90 vai de encontro ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República, porquanto cabe ao julgador particularizar a reprimenda do condenado, conforme as circunstâncias do caso concreto. A propósito, cumpre transcrever os fundamentos do voto do Ministro Relator Dias Toffoli, in verbis: "No inciso XLIII do rol das garantias constitucionais artigo 5º - afastam-se, tão somente, a fiança, a graça e a anistia, assegurando-se, em inciso posterior (XLVI), de forma abrangente, sem excepcionar essa ou aquela prática delituosa, a individualização da pena. No tocante ao tema, assinalo que, a partir do julgamento do HC nº 82.959/SP (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 1º/9/06), esta Corte Suprema passou a admitir a possibilidade de progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos, dada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da lei nº 8.072/90. Tal possibilidade veio a ser acolhida posteriormente pela Lei nº 11.464/07, que modificou a Lei nº 8.072/90, positivando-se, desse modo, a possibilidade da mencionada progressão. Contudo, como já dito, essa lei estipulou que a pena imposta pela prática de qualquer dos crimes nela mencionados fosse, obrigatoriamente, cumprida inicialmente no regime fechado. Tal como já indagado no julgamento do HC nº 82.959/SP, tinha e tem o legislador ordinário poder para isso estabelecer? A minha resposta é negativa. Destarte, tenho como inconstitucional o preceito do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, o qual foi modificado pela Lei nº 11.464/07." (grifo nosso) Consoante orientação da Corte Suprema, independentemente do caráter hediondo do crime, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o julgador observar o disposto no artigo 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, em atenção ao princípio da individualização da pena. O fato de ter sido "supostamente" apreendido entorpecente não constitui, por si só, motivação suficiente à determinação do regime inicial fechado, notadamente porque todas as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a quantidade de droga revela-se pequena. A esse respeito, dispõe os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça, verbis: E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART.28 DA LEI Nº 11.343/06 - TESE REJEITADA - ELEMENTOS QUE INDICAM A CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO - EXASPERAÇÃO EXACERBADA DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33 § 4º DA LEI Nº 11.343/06 - TESE ACOLHIDA - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a consumação delitiva é alcançada pela mera prática de qualquer das condutas típicas previstas na norma penal incriminadora (Lei nº 11.343/06, art.33, caput), independentemente de qualquer intenção específica do agente no tocante a obtenção de benefício financeiro com a comercialização do entorpecente. No caso, a ação do apelante caracterizou a conduta típica de "ter em depósito", pelo que ficou consumada a infração de tráfico. Desse modo, não há possibilidade de acatar a tese de desclassificação do crime de tráfico para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, até porque a consumação desse delito exige a comprovação do elemento subjetivo específico "para consumo próprio", cujo o ônus da prova incumbe ao réu, o que não ficou provado nos autos. A pena-base deve ser aplicada de forma justa e fundamentada, ou seja, valorada de maneira proporcional de acordo com as circunstâncias judiciais no caso concreto. O apelante preenche os requisitos legais, para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Dessa forma, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que diante da natureza e quantidade da droga (3g de crack), a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), montante que se mostra justo e suficiente para prevenção e reprovação do delito. Cabível regime mais brando na hipótese, pois o réu é primário, a quantidade da droga 3g (três gramas) de crack - não é expressiva se comparada aos parâmetros estaduais, bem como a quantidade da pena (1 ano e 11

meses) inferior a 4 anos, possibilitam a aplicação de regime mais favorável ao réu. Cabível a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da Execução, uma vez que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Destarte, considerando que o réu foi beneficiado com a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e diante da quantidade da droga, mostra-se recomendável a medida. (TJMS; Apelação n. 0004116- 19.2012.8.12.0002 Dourados; Relator Designado Des. Dorival Moreira dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 04/11/2013). (grifo nosso) Em outro caso, a Corte assim se manifestou, in verbis: "(...) é cabível regime mais brando na hipótese, pois a ré é primária, a quantidade da droga (9,42 g de crack) não é expressiva, bem como a quantidade da pena (1 ano e 08 meses de reclusão) inferior a 4 anos, possibilitam a aplicação de regime aberto. Assim, deve ser alterado o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e observada a natureza e a quantidade da droga, nos moldes do art. 42 da Lei 11.343/06, por se mostrar mais adequado à prevenção e reprovação do delito. (TJMS; Apelação n. 0001619- 51.2012.8.12.0028 Bonito; Relator Designado Des. Dorival Moreira dos Santos, 1ª Câmara Criminal; j. 19/08/2013). (grifo nosso) Nesse sentido a decisão proferida e. STF, verbis: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CP). IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS SEVERO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 719-STF. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DA LEI 11.343/06). INCONSTITUCIONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal determina que "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 3. "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula 719). 4. In casu, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente o writ lá impetrado para reduzir a pena cominada ao paciente para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, fixando, todavia, o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, sob o único fundamento de ser esse o regime "mais adequado", tendo em vista "a potencialidade destruidora do crack". 5. Consoante destaca o Ministério Público, "não havendo registro de antecedentes, a pena aplicada (3 anos e 8 meses de reclusão), inferior a quatro anos, permite o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, 'c'), porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (HC nº 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, Informativo nº 670)". (...) 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual eleita e concedida ordem de ofício, ex officio, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, determinando ao Juízo que avalie os requisitos necessários à conversão da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. (HC 108208, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03- 2013) (grifo nosso) Por derradeiro, na remota hipótese de aplicação de qualquer sanção penal (o que se admite apenas para argumentar) o fato de acusado ostentar antecedentes não pode jamais servir de causa de aumento da pena, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência Em um sistema penal democrático, fundado no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo (cf. STF - HC 107108, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30/10/2012), o cidadão não pode sofrer sancionamento por sua personalidade, pois cada pessoa tem a

personalidade que lhe é possível ter (cf. Carvalho, Salo. "Aplicação da pena no Estado Democrático de Direito e Garantismo: considerações a partir do Princípio da Secularização". p. 46 e seguintes. in CARVALHO, Amilton Bueno de & CARVALHO, Salo de. "Aplicação da Pena e Garantismo". Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001). O cidadão deve responder pelo fato criminoso imputado (Direito Penal do fato), e não pelo seu comportamento ou por seus traços de personalidade (Direito Penal do autor). O nobre jurista Luigi Ferrajoli, adverte, aliás, que "O Estado, com efeito, não deve imiscuir-se coercitivamente na vida moral dos cidadãos nem mesmo promover-lhes, de forma coativa, a moralidade, mas somente, tutelar-lhes a segurança, impedindo que os mesmos causem danos uns aos outros. Em segundo lugar, se aplicado ao processo, e consequentemente aos problemas da jurisdição, o princípio normativo da separação impõe que o julgamento não verse sobre a moralidade, ou sobre o caráter, ou, ainda, sobre aspectos substanciais da personalidade do réu, mas apenas sobre os fatos penalmente proibidos que lhe são imputados e que, por seu turno, constituem as únicas coisas que podem ser empiricamente provadas pela acusação e refutadas pela defesa. Assim, o juiz não deve indagar sobre a alma do imputado, e tampouco emitir veredictos morais sobre a sua pessoa, mas apenas individuar os seus comportamentos vedados pela lei. Um cidadão pode ser punido apenas por aquilo que fez, e não pelo que é" (in Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 2ª Edição São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 208). A jurisprudência já exarou o seguinte "PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAR A PUNIÇÃO. As circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, previstas no art. 59 do CP, só devem ser consideradas para beneficiar o acusado e não para lhe agravar mais a pena. A punição deve levar em conta somente as circunstâncias e conseqüências do crime. E excepcionalmente minorando-a face a boa conduta e/ou a boa personalidade do agente. Tal posição decorre da garantia constitucional da liberdade, prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Se é assegurado ao cidadão apresentar qualquer comportamento (liberdade individual), só responderá por ele, se a sua conduta ('lato senso') for lícita. Ou seja, ainda que sua personalidade ou conduta social não se enquadre no pensamento médio da sociedade em que vive (mas seus atos são legais), elas não podem ser utilizadas para o efeito de aumentar sua pena, prejudicando-o. (Apelação Crime Nº 70000907659, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 15/06/2000) Para "sepultar" de vez o assunto e demonstrar inequivocamente a impropriedade de se valorar a personalidade do agente (e a conduta social) com o escopo de recrudescer a pena do acusado, o atual anteprojeto de Código Penal em tramitação no Congresso Nacional retirou tais elementos do dispositivo de trata da individualização da pena (artigo 75). Na exposição de motivos do indigitado anteprojeto consta o seguinte "A objetivação das circunstâncias judiciais. A proposta retira do espaço de cognição judicial, para fins de dosimetria da pena, aspectos subjetivos como a conduta social e a personalidade do agente. A conduta social porque permitia valorações de cunho moral ou de classe ou estamento social. Já a personalidade do agente se apresentava como de difícil aferição pelo julgador, pois o processo crime raramente traz tais indicativos psicológicos que permitissem um exame acurado. A retirada destes elementos de grande subjetividade condiz, além de tudo, com o Direito Penal do fato, e não do autor. A proposta é prestigiar as circunstâncias do fato criminoso e a conduta do agente, como grandes elementos para o encontro da pena individual. Daí a menção aos fins, meios, modo de execução e conseqüências do crime. Isto há de permitir ao julgador exame apropriado da gravidade do fato e da culpabilidade do agente, evitando majorações ou diminuições com base na personalidade ou vida social daquele." (destaquei). Afora isso, no caso concreto não houve exame de natureza antropológica, psicológica ou psiquiátrica para aferir se realmente o réu "possui índole violenta", inexistindo nestes autos elementos hábeis que possam permitir que o julgador profira "diagnóstico" de tal natureza. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a absolvição do acusado, aplicando-se o artigo 386, inciso V, VI, e VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a sua condenação; e subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, REQUER que a condenação seja aplicada em seu mínimo legal, tendo em vista que a quantidade de

droga apreendida não é expressiva, conforme argumentação já exposta, requer ainda que o Regime Inicial seja o semi-aberto. Nesses Termos, Pede Deferimento. Rio das Pedras-SP, 28 de março de 2022.". Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "1. DO RELATÓRIO Trata-se de ação penal de iniciativa pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MAYCON WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 18h10, na Avenida Rosina Figureli Coury, 1800, Núcleo Habitacional Lucia Taranto Marrano, no Município de Rio das Pedras/SP, o denunciado trazia consigo e guardava 23 (vinte e três) porções de maconha (massa líquida: 39,2 + 3,2 gramas) e 02 (duas) porções de crack (massa líquida: 0,3 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinando-se as substâncias ao comércio ilícito. Notificado (fls. 126), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 130). A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 135). Citado o réu (fls. 153), seguiu-se, então, audiência de instrução, debates e julgamento, concluída nesta data. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Eis, em breve síntese, o relatório. Passo a decidir. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO A materialidade delitiva está comprovada às fls. 03/06, 15/17, 18/26 e 82/83. A autoria, por sua vez, é certa. O PM Elvis Barbosa de Oliveira afirmou que: durante patrulhamento avistou duas pessoas em local já conhecido por ser ponto de venda drogas; abordou ambos, mas nada de ilícito foi encontrado; depois de um tempo, recebeu informação do Copom de que, naquele local, os sujeitos que a pouco haviam sido abordados estavam traficando; retornou ao local e abordou a dupla novamente; desta vez, localizou dinheiro e maconha com o réu; próximo de onde o réu estava havia mais algumas porções de maconha e pedras de crack; as drogas estavam há alguns metros do réu; com Ronilson não havia nada; o réu declarou que era usuário e que estava guardando a droga para terceira pessoa; foi a PM quem fez buscas pelo local e localizou as drogas, não foi o réu quem indicou o local onde elas estavam; não se recorda se as porções de maconha encontradas com o réu eram semelhantes aquelas que estavam na vegetação próximo a ele; já havia abordado o réu anteriormente, inclusive no mesmo local, sempre sob a suspeita de tráfico. De seu turno, o PM Lucas Duarte Mauron confirmou a dinâmica descrita pelo colega de farda. Destaco do seu testemunho as seguintes informações: a) a porção de maconha que estava com o réu era idêntica àquelas que foram encontradas na vegetação há alguns metros dele (mesma embalagem e natureza); b) não conhecia o réu de outras abordagens; c) o réu confessou que estava guardando a droga; e d) o local onde o réu estava é conhecido como ponto de venda de drogas. A testemunha de defesa Richard Cesarino declarou que: não estava no dia dos fatos; conhece o réu, mas acha que ele não tem envolvimento com drogas; conhece ele há pouco tempo, não sabe se ele é dependente químico. Finalmente, o imputado declarou que: a acusação não é verdadeira; a droga estava em um barranco há uns 50m de onde o declarante estava; foi ao local comprar drogas; estava com cinco reais no bolso para comprar uma pedra de crack; entregou o dinheiro a um traficante que se dirigiu até uma casinha para pegar a droga; nesse instante a PM chegou e apreendeu o declarante e Ronilson; disse aos PMs que a droga não lhe pertencia; estava com um cachimbo no bolso que não foi apresentado pelos PMs; é verdade que foi abordado duas vezes pela PM; estava com Ronilson nas duas abordagens; Ronilson também é usuário; já conhecia o PM Santos anteriormente, ele bateu no declarante em virtude do declarante ter furtado um tanquinho; não é amigo de Ronilson, mas já usou drogas com ele várias vezes; quando foi abordado pela PM já não tinha mais dinheiro, havia entregado os R\$ 5,00 ao traficante; não possuía R\$ 33,00 em espécie; não admite ter dito aos PMs que estava aguardando as drogas; a declaração de Ronilson na DeIPol não é verdadeira. Pois bem. Conquanto o réu negue a prática do tráfico, há prova suficiente para condená-lo. Os PMs ouvidos em juízo prestaram declarações sólidas e uniformes, não havendo qualquer indício de que tenham faltado com a verdade. A versão deles, ademais, está em consonância com a declaração policial de Ronilson da Cruz Nunes dos Santos, que confirmou que quando da segunda abordagem os militares

localizaram com o imputado "(...)2 invólucros de maconha e R\$ 33,00 (trinta e três reais) em dinheiro.

Relata o declarante logo em seguida os policiais fizeram buscas nas imediações e localizaram certa quantidade de drogas, esclarece que não visualizou o momento em que os policiais encontraram a droga. (...)” (fls. 08). Frise-se que as porções de maconha localizadas com o réu eram idênticas aquelas que estavam escondidas na vegetação próxima a ele, como destacado pelo PM Lucas Duarte Maroun e como se confirma das fotografias de fls. 15 e 17. De rigor, portanto, a condenação. O réu já foi condenado anteriormente por furto (Processo nº 3001182-38.2013.8.26.0511) e tráfico de drogas (Processo nº 0000367-24.2015.8.26.0511) – fls. 138/144. Presente a recidiva, não se permite a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por expressa proibição legal. 3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei de Drogas c.c. art. 61, I, do Código Penal. Passo, doravante, a dosar a pena do réu. Na primeira fase, início pela análise das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade das substâncias não é elevada, razão pela qual este vetor não será considerado negativo. Em relação à natureza, nada a se anotar. Não há elementos nos autos para avaliar a personalidade e a conduta social do réu. Passando para as circunstâncias do art. 59 do CP, considera-se o grau de culpabilidade como normal à espécie. O réu não possui Maus antecedentes. A personalidade e a conduta social já foram avaliadas. A motivação do crime é o propósito de lucro fácil, circunstância já considerada pelo legislador para o estabelecimento da pena mínima cominada. As circunstâncias e as consequências do crime nada têm de especiais a justificar o aumento da pena-base. Por se tratar de crime vago, incabível a valoração do comportamento da vítima. Não havendo circunstâncias negativas, fixo a pena-base no mínimo legal. Passando à segunda fase, há a agravante da reincidência. Considerando que o réu possui 02 (duas) condenações anteriores, uma delas, inclusive, por tráfico de drogas, majoro a pena de 1/4 (um quarto). Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. No tocante ao regime inicial, declaro, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, por ofensa ao princípio da individualização da pena (cf. STF, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli). A estipulação do regime inicial será feita, portanto, com fundamento no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Considerando a reincidência do réu, de natureza específica, inclusive, fixo o regime inicial fechado. À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 avós do salário mínimo. 4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS Considerando que o réu respondeu ao presente processo em liberdade e que não há motivo para a decretação de sua custódia cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Condono o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, observada a gratuidade, ora deferida. Autorizo a destruição das drogas. Comunique-se. Decreto a perda do numerário em favor da União. Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, com a concordância das partes. Eu, ANA LUISA LORANDI FALDA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Deseja recorrer desta sentença: sim () não (X).

ADVOGADO:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

RÉU:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu. O ilustre advogado já sai intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal."